



刑法

「法益保護」

中央大学教授
高橋直哉
TAKAHASHI Naoya

1 刑法の任務

刑法総論の教科書を読むと、刑法の任務は法益の保護にある、と書かれている。このような考え方が具体的に顕在化してくる場面は、2つに大別することができる。

1つは、刑罰法規の意味を明らかにする場面である。ここでは、当該刑罰法規の保護法益を明らかにした上で、その法益を保護するという目的に照らして合理的な解釈がなされなければならない。ここでは、法益概念は、目的論的解釈の要としての役割を担っている。ところで、法益とは「法によって保護される（べき）利益」などと表現されるが、刑法には必ず立法目的があり、その目的の追求によって実現されるべき利益（あるいは状態）を法益と理解するならば、保護法益のない刑法などおおよそあり得ない。その限りでは、いかなる刑罰法規であっても、その保護法益を明らかにし、その法益を保護するという目的に照らして合理的な解釈をすることは可能である。ここでは、当該刑罰法規は所与の前提とされ、法益概念は、その意味内

容を説明する際の指針として機能する。

もう1つは、刑罰法規の妥当性を検討する場面である。ここでは、法益概念に、当該刑罰法規の妥当性を批判的に検討する機能が期待されている。ここでは、法益を保護しない刑罰法規があり得るという認識に立ち、そのような刑罰法規の正当性を否定することに重要な意義がある。例えば、刑法は法益を保護するためにあり、社会倫理を維持することは刑法の役割ではない、といった主張がなされる場合がこれである。ここでは立法目的それ自体が、法益概念に照らして批判的に吟味されることになる。したがって、このような法益概念は、既存の刑罰法規の解釈のみならず、刑事立法を規制する機能も担うことになる。刑法の任務は法益の保護にある、という考え方が、目的論的解釈の枠を超えて、あるべき刑罰法規の限界を画する政策原理として主張される場合、これを特に法益保護主義と呼ぶ¹⁾。

2 法益概念の歴史²⁾

法益という言葉は「Rechtsgut」というドイツ語の訳語である³⁾。ドイツ刑法学におけるこの概念の淵源は、ビルンバウムが、1834年の論文で、犯罪を「法的な財 rechtliches Gut」の侵害として把握する見解を主張したところにある、とされる。もっとも、このビルンbauムの法益概念が、当初から可罰性を制限する自由主義的な性格のものであったのかについては議論がある⁴⁾。

その後、法益概念は、ビンディングやリストの議論を通じてドイツ刑法学における中核的概念に成長し、国家が処罰することが許されるのはどのような行為かを判断する際の基準を提供しようとする実質的犯罪概念において重要な地位を占めるようになった。とりわけ、第2次大戦後の（西）ドイツにおける刑法改正をめぐる議論において、モラリズムを批判し、刑法の任務は法益保護にあるということが強調されて以降は、法益概念の歴史的形成過程をどのように

1) 山口厚『刑法総論〔第3版〕』（有斐閣、2016年）4頁以下、松原芳博『刑法総論〔第3版〕』（日本評論社、2022年）15頁以下参照。

2) 法益概念の歴史に関しては、伊東研祐『法益概念史研究』（成文堂、1984年）、嘉門優「法益論／不法本質論」伊東研祐＝松宮孝明編『リーディングス刑法』（法律文化社、2015年）165頁以下参照。

3) 「Recht」は「法」を意味し、「Gut」は「財」を意

味する。したがって、直訳すれば「法的財」となるが、わが国では「法益」という用語が定着している。これは、この概念がわが国に導入された当初、「法的に保護される利益」「生活利益」などと表現するリストの法益概念の影響が大きかったためではないと思われる。

4) 例えば、伊東・前掲注2)29頁以下と内藤謙『刑法理論の史的展開』（有斐閣、2007年）140頁以下を比較参照されたい。

評価するにせよ、現に法益概念が刑法を限界づけるという自由主義的な機能を担うものとして構想されていることについては（それが成功しているかどうかはともかく）大方のコンセンサスが得られているといつてよい。

法益概念がわが国に紹介されるようになったのは20世紀初頭であるが、当初は刑法を限界づけるという意識は希薄であった。法益概念の自由主義的な機能が強調される契機となったのは、ドイツと同じく、第2次大戦後の刑法改正をめぐる議論である。そこでは、法益保護思想に基づく法益論的アプローチを採用する論者たちが、道義的応報思想に基づく伝統的な規範論的アプローチとの違いを強調し、刑法の拡張傾向、とりわけモラリズムを厳しく批判した。この対比が、刑法の任務は法益保護にあるとする結果無価値論と刑法の任務は社会倫理の維持にあるとする行為無価値論の対立として刑法学全体を覆う論争へと発展していったのは周知のことである。ここにおいて、法益論が、自由主義的な観点から刑法を限界づける理論として語られる文脈が形成されることとなった。

法益論の現在

このような歴史を経て展開されてきた法益論は、現在、どのような状況にあるだろうか？

まず、刑罰法規の意味を明らかにするという場面においては、法益概念は依然として解釈の要として重要な役割を果たしている。例えば、実行行為性の判断においては、法益侵害の危険性が重要な考慮要因となる。違法性に関しては、法益侵害・危殆化が必要とされ、違法性阻却の場面では保護法益と侵害法益の比較衡量が重要な意味をもっている。錯誤論においては、構成要件の実質的重なり合いを認めるために保護法益の共通性が必要であるとされる。未遂犯や危険犯の成否を判断する際には、法益侵害の危険の肯否が決定的な意味をもつ。継続犯と状態犯の区別や罪数判断においても、法益概念は重要な役割を担っている。また、刑法各論の領

5) もっとも、このように法益概念が刑罰法規の解釈において重要な地位を占めるに至ったことは、犯罪論における結果無価値論の勝利を意味するものではない。わが国の行為無価値論は、行為無価値と結果無価値の双方を考慮する二元的なものであり、法益侵害・危険の要素も取り込んでいるため、結果無価値論との違いはかつて喧伝されていたほど大きくはないように見える。実際、その具体的帰結のレベルでは、行為無価値論と結果無価値論との間に収

域では、保護法益によって犯罪を分類する手法が完全に定着している。法益という概念を抜きにして今日の犯罪論を語ることは不可能である⁵⁾。

このように法益概念は、刑罰法規の解釈における不可欠の方法論的ツールになっているが、刑罰法規の妥当性を批判的に検討する場面においては様相が異なる。特に、刑事立法を規制するという局面では、法益論はかなりの苦戦を強いられている。以下では、そのような問題を2つ取り上げてみよう。

1つ目は、処罰の早期化である。法益論は、法益を侵害・危殆化する行為のみを処罰対象とすることによって、刑事立法を規制しようとしてきた。しかし、近時の刑事立法では、法益侵害はもとより具体的な危殆化よりもかなり前の段階の行為を犯罪化しているように見える場合が多くなっている⁶⁾。例えば、他人のクレジットカードの磁気ストライプ部分の電磁的記録をコピーして盗み取る行為（スキミング）は処罰の対象であり（刑163条の4第1項）、更にその未遂も処罰される（刑163条の5）。したがって、加盟店の信用照会端末（CAT）にスキミング装置を取り付けた段階で既に可罰的になる。クレジットカードの電磁的記録不正作出（刑163条の2第1項）との関係で見ると、スキミングはその予備に当たるが、更にその未遂（予備の未遂）も処罰されていることになる。仮に、支払用カードを構成する個々の電磁的記録の真正とそれに対する社会の信頼を保護法益とするならば、本罪に当たる行為がそのような法益を具体的に危殆化するといえるかには疑問が生じ得るであろう。これに対して、立案当事者は、支払用カードを用いた支払決済システムに対する社会的信頼を本罪の保護法益としていた⁷⁾。ここでは、諸要素の機能的な関係複合体であるシステム、抽象的・観念的な法益の担い手としての社会、非物質的な要素である信頼が結びつくことによって、どのような場合に、いかなる機序をもって、どの程度侵害される（あるいは危殆化される）のかが把握しにくい法益

斂傾向が見られる。とりわけ、理論と実務の架橋が意識されるようになってからは、この傾向は一層顕著なものとなっている。

6) 特に情報処理にまつわる技術が関連する経済犯罪、ネット犯罪、サイバー犯罪等の領域では、このような傾向が顕著である。

7) 長瀬敬昭「刑法の一部を改正する法律について」警察学論集54巻9号（2001年）107頁。

が構想されている⁸⁾。このような侵害や危殆化の機序・様態が不明確な法益概念が前提となるならば、犯罪化のために法益侵害・危殆化を要求したとしても、その限定機能は乏しいものとなるであろう。むしろ、このような法益概念は、積極的に立法理由を付与する役割を担うことになりそうである。

このような処罰の早期化が生ずる背景には、国民による安全・安心への要求の増大と、それに対応する予防型刑法への傾斜があるとされる⁹⁾。また、このような刑事立法は、国民の安全・安心の要求に応えるという文脈で政治的イシューとなる場面が少なくない。そこでは、法益の保護に具体的にどのように役立つのかということよりも、国民の安全・安心の要求に応えているという姿勢¹⁰⁾を示すことの方に重点が置かれる。このような刑事立法は、「象徴的立法」などと呼ばれ、法益との関連性が希薄化していると批判される¹¹⁾。

2つ目は、科学技術の発達により、これまで経験したことのない新たな倫理問題が出現してきたことである。代表的なのは生命倫理と環境倫理である。例えば、クローン技術の発達は、その技術をどの範囲で利用してよいかという問題をもたらしした。現行法ではヒトクローン胚を移植する行為は処罰の対象となっている（ヒトに関するクローン技術等規制法16条・3条）が、これがどのような法益を保護するものなのかははっきりしない。「人間の尊厳」がその候補として挙げられることもあるが、立法を規制する概念としてはあまりに抽象的過ぎるであろう¹²⁾。環境倫理においては、動植物など自然

それ自体の保護と将来世代の保護が重要な問題となっている。人間の利益とは切り離して自然それ自体の保護を目的とすることは、従来自明視されていた人間中心主義からの離反を意味する¹³⁾。まだ見ぬ（そして実際に会うこともないであろう）将来世代の利益を保護することにも、現に今生きている人間の利益とは切り離されているという意味で同質の問題がある¹⁴⁾。いずれも、現に今生きている私たちの利益に還元できないものについて法益性を認めることができるかが問われるが、伝統的な法益論の枠組みではこれは認めにくい¹⁵⁾。むしろ、ここでは、既に存在している法益の保護というよりは、新たな規範の形成のために刑法が用いられているようにも見える。そのような観点から、刑法による規範形成機能が唱えられることもある¹⁶⁾。

ここに挙げた例は、いずれも法益論にとって看過し難い問題であると同時に悩ましい問題でもある。刑罰法規の妥当性を批判的に吟味するに足るだけの具体的な内容をもつ法益概念を前提とし、その侵害・危殆化を要求するならば、このような刑事立法に対しては否定的・消極的な回答が与えられなければならないであろうが、その帰結の妥当性には疑問がさしはさまれることも少なくない。他方で、このような刑事立法を説明できるような法益概念は、その内実が希薄化し、立法規制機能を十分に果たすことは困難となる。ここに法益概念の大きなジレンマがある¹⁷⁾。このジレンマを解消し、法益概念の批判的な機能を救い出すことができるのか¹⁸⁾、それとも法益概念の立法規制機能に限界を見出し、それとは別の立法を規制する理論

8) この関係では、「普遍的法益」という概念が重要である（金尚均『危険社会と刑法』〔成文堂、2001年〕17頁以下参照）。

9) いわゆる「危険社会」と刑法の関係については、金・前掲注8）、関哲夫「危険社会における法益概念の役割」國學院法学53巻3号（2015年）49頁以下参照。また、「不安社会」という観点からの分析として、松原芳博「国民の意識が生み出す犯罪と刑罰」世界761号（2007年）53頁以下参照。

10) 類似の問題は、国際的な要請に応えるという政治姿勢を示すという形で現れる場合もある。例えば、テロ等準備罪（組織犯罪6条の2）の創設には、そのような気味がないわけではない。

11) 関・前掲注9）68頁・松原・前掲注9）56頁以下参照。

12) この分野における「人間の尊厳」のとらえ方については、岩佐宣明「象徴としてのヒト胚——日本のヒト胚政策における〈人間の尊厳〉概念に関する一考察」加藤泰史編『尊厳概念のダイナミズム——哲学・応用倫理学論集』（法政大学出版局、2017年）211頁以下参照。

13) 三上正隆「動物虐待関連犯罪の保護法益に関する一考察——『動物の権利』に関する議論を参照して」刑法59巻2号（2020年）276頁。

14) これは、いわば現在世代中心主義からの離反であるといえるであろう。

15) 「自然（将来世代）を守ることができるのは人間（現在世代）だけなのであるから、人間（現在世代）には自然（将来世代）を守る義務がある」という主張は、「人間（現在世代）『である』という『存在』から「自然（将来世代）を保護する『べきである』という『当為』が導かれる構造をもっている。そのため、私たちの利益を云々するよりも前に私たちの責任が立ち現れやすいが、これを刑法によって強制することは、伝統的な法益論の立場からすると法による倫理の強制のように映ずるであろう。

16) 伊東研祐『環境刑法研究序説』（成文堂、2003年）3頁以下。

17) 井田良『変革の時代における理論刑法学』（慶應義塾大学出版会、2007年）32頁以下参照。

18) 嘉門優『法益論——刑法における意義と役割』（成文堂、2019年）は、この可能性を模索する。

的枠組みを構築すべきか¹⁹⁾が、新たな論点となりつつある。



今後の展望

以上のような法益論の歴史・現状を踏まえて、法益論の今後を占う意味で重要だと思われるポイントについて、最後に簡単に言及しておきたい。

第1に、刑法の任務は法益保護にある、という考え方は、法益を保護するために刑法を用いるべきであるという積極面と、法益の保護に役立たない刑法を用いるべきではないという消極面とを含み得る。この2つは同じことであるように見えるが、実際にはかなり性質を異にする主張となって表れる。積極的な主張は、どのような行為を犯罪とすべきか、という犯罪化の理由（目的）に関わるものであるのに対し、消極的な主張は、どのような行為を犯罪としてはならないのか、という犯罪化の対象（目的達成のための手段）に関わるものである。法益論が、刑法の目的それ自体を規制するものであるならば、ある行為を犯罪とすることが法益保護に役立つということを、少なくとも犯罪化の理由の1つとしなければならない。そのように考えた場合には、この積極面と消極面を共通の法益概念で統一しながら、同時にそのような法益概念にどの程度立法規制機能を担わせることができるのかが問われなければならないであろう。

第2に、法益の保護に役立たない刑法を用いるべきではないという主張と、法益を侵害・危殆化しない行為を犯罪としてはならないという

主張とは同じものではない。前述した処罰の早期化という現象からもうかがわれるように、それ自体は法益を侵害・危殆化しない行為であっても、それを規制することによって法益保護に資するケースは多々考えられる。法益保護に役立つか否かという観点からだけでは、法益を侵害・危殆化しない行為を犯罪としてはならないという結論を直ちに導くことはできない。それでもなお法益を侵害・危殆化しない行為を犯罪としてはならないという主張を維持しようとするのであれば、それを支える実質的な根拠を更に探求しなければならないだろう²⁰⁾。

第3に、法益を侵害・危殆化しない行為を犯罪としてはならないということが例外を認めない一元的な主張なのだとすれば、犯罪化が許容される全ての場合について、何が法益であり、その法益を侵害・危殆化する行為とはどのようなものなのかを説明できなければならない。ここで、法益概念を、その実質的な内容が明らかで、その侵害・危殆化の機序を合理的に把握することができるように具体的に記述すれば、そのような法益概念は、強い立法規制機能をもつことになるであろう。しかし、そのような法益概念によって正当化できる刑法の範囲は狭くなるを得ないため、合理性を否定できない刑法を説明することが難しくなる場合が生じ得る。他方で、合理的であると考えられる刑法をカバーできるように法益概念を拡張しようとするれば、それは抽象的で記述的内容の乏しいものとなり、立法規制機能が削がれることになるであろう²¹⁾。

前述した法益概念のジレンマが関係するの

19) 井田良『講義刑法学・総論（第2版）』（有斐閣、2018年）26頁以下、上田正基『その行為、本当に処罰しますか——憲法的刑事立法論序説』（弘文堂、2016年）、仲道祐樹『法益論・危害原理・憲法判断——刑事立法の分析枠組に関する比較法的考察』比較法学53巻1号（2019年）25頁以下、亀井源太郎『刑事立法学の構想』法学会雑誌（東京都立大学）62巻1号（2021年）157頁以下等参照。

20) この点に関しては、刑法の補充性・謙抑性・断片性ということが指摘される。適切な指摘であるが、問題はこれによって刑法が控えめであるべき理由である。行き過ぎた法益保護によって生ずる弊害を避けるためであるということがその理由だとするならば、法益保護とこれらの制約とは対抗関係に立つことになるが、その場合にはこれらの制約の重要性を法益保護とは別の観点から基礎づける必要がある（そのような方向の議論として、松原・前掲注1）20頁）。他方で、そうすることが結局は最適な法益保護につながるからだという点にその理由を求めるならば、これらは法益保護の内在的制約であることになるが、その場合には最適性を判断する基準・方法が問題となるだろう。

21) 倫理学では、記述的内容が豊富かつ具体的で、その意味を確定する上で規範的な判断を必要とする程度が小さい概念を「厚い thick」概念と呼び、記述的内容が乏しく抽象的で、その意味内容を確定するために更なる規範的な判断を必要とする程度が大きい概念を「薄い thin」概念と呼ぶことがある（バーナド・ウィリアムズ〔森際康友＝下川潔訳〕『生き方について哲学は何が言えるか』（ちくま学芸文庫、2020年）第8章参照）。これに照らすと、一般的に定義される法益概念は、性質上「薄い」概念とならざるを得ないであろう。このような「薄い」概念は、規範的な判断の余地を幅広く残すため、どのような価値観を前提とするかによって判断が相対化しやすい。その意味で、法益概念には、価値判断を規制する能力が乏しくなる傾向が本来的に内在しているといえる。実定法の価値基準にしたがって法益を理解しようとする試み（嘉門・前掲注18）79頁以下）は、前提となるべき価値判断を固定することによって判断が相対化する範囲を縮小しようとするものだと見ることができるが、その前提となる価値判断の出自・正当性が更に問われることになるであろう。

は、この点である。ここで、法益概念の立法規制機能を重視し、その実質的な内容を具体化・精緻化する方向に進むのも1つの選択である。それは、従来の法益論の立場を堅持しようとするものであるが、その場合には、現代社会の様相に合わせてより洗練された法益概念を提示できるかが課題となるであろう。

他方で、そのような選択をしない場合には、従来に比べて法益論の役割を縮小することになるであろう。しかし、そのような方向に進んでも、刑法の適切な射程を画するという問題がなくなるわけではない。この問題に答えるためには、私たちが生きる社会において何が法的に保護すべき価値あるものなのか、という政治的な問いを避けて通ることはできない。「何が法的に『保護すべき』利益か」を問題とする法益論の思考枠組みは、刑法のあり方を考える上で、

このような価値判断を伴う規範的な問いに取り組むことが重要である、ということ意識させ、議論のフォーラムを創り出すという意味において、法益論の立法規制機能に懐疑的な者にとっても、依然として訴求力をもち得るであろう²²⁾。

刑法の任務は法益保護にある、ということ、を、ただ呪文のように繰り返しても得られるものはほとんどない。この主張が何を狙いとし、それを達成するためには何が必要か、ということ、をじっくりと考えることが大切である。その過程では、「うっそうたる争点のジャングル」²³⁾に遭遇するかもしれないが、刑法について真摯に取り組もうとする者は、そこを通り抜けなければならない。

(たかはし・なおや) ㊦

22) この関連では、法益論との類似性が指摘される「危害原理 harm principle」に関する議論動向も興味深い。古典的なミルの考え方によれば、他者に対する危害の防止が国家による干渉を正当化する唯一の目的となる。このような危害原理は、一元的な立法制約原理となる。これに対して、ファインバーグのように、他者危害の防止に加えて、他者に対する重大な感情侵害を防止するための犯罪化も許容され得る（この「感情侵害原理 offense principle」については、亀田悠斗「感情侵害原理 (Offense Principle) を巡る議論の展開(1)(2・完)」阪大法学 70 巻 5 号 (2021 年) 467 頁以下・6 号 (2021 年) 223 頁以下参照）と考えるならば、危害原理は一元的な立法制約原理ではない。し

かし、ファインバーグは、危害原理と感情侵害原理を「リベラルな立場」における犯罪化の下位原理として主張しており（亀田・前掲(1) 477 頁）、ここでは「リベラルな立場」が一元的な立法制約原理の役割を担う。ミルの危害原理とファインバーグのリベラルな立場を比較すると、後者の方がより「薄い」原理である。その分、後者の方が立法を規制する機能は弱まるが、依然として自由社会における刑法のあり方を制御する機能は有している。

23) クラウス・ロクシン（山中敬一監訳）『刑法総論(1) 基礎・犯罪論の構造〔第4版〕〔翻訳第1分冊〕』（信山社、2019 年）17 頁。